

1513972-26.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDO DE LIMA LUIZ

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... posterior, mas ele já foi preso por tráfico pela equipe do depoente; foi em local diferente, também conhecido pela prática de tráfico; havia somente ele no centro da praça, sentado; o réu saiu andando rápido; a sacola ficou próximo ao local em que ele estava sentado; fez prisão em outra ocasião, em que estava em uma residência onde já foram efetuadas diversas prisões, também ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1513972-26.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513972-26.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2153110/2021 - 33º D.P. PIRITUBA, 18346078 - 33º D.P. PIRITUBA, 1695/21/333 - 33º D.P. PIRITUBA, 2153110 - 33º D.P. PIRITUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO TUMIERO DE OLIVEIRA

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO DE LIMA LUIZ

Vistos.

1 O relatório

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra FERNANDO TUMIERO DE OLIVEIRA, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, c.c. 61, II, "j", do Código Penal.

Narrou a peça acusatória (fls. 72-73) que:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em 7 de junho de 2021, às 10h36min, na Rua Comendador Emilio Romi, altura do nº 25, Pirituba, nesta Capital, em situação de fragilidade social decorrente de calamidade pública, FERNANDO TUMIERO DE OLIVEIRA, com 19 anos de idade, qualificado a fls. 15, foi surpreendido trazendo consigo, para fins de tráfico, 73,3g (setenta e três gramas e três decigramas) de Tetraidrocanabinol, mais conhecida como "maconha", em 46 (quarenta e seis) porções; e 7,84g (sete gramas e oitenta e quatro decigramas) de "cocaína", em 10 (dez) invólucros plásticos; drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme autos de exibição e apreensão de fls. 7/8 e de constatação de fls. 11/14, bem como

laudo químico-toxicológico a ser oportunamente juntado.

Segundo apurado, na manhã dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento pela região, conhecido "ponto" de tráfico de drogas, quando avistaram o indiciado, em atitude suspeita, pelo que resolveram abordá-lo. Ao notar a aproximação policial, o agente dispensou uma sacola plástica que trazia consigo e tentou empreender fuga, sendo detido logo em seguida pelos agentes.

Dentro da sacola dispensada pelos agentes, os PMS acharam as citadas porções de maconha e cocaína, já embaladas e prontas para venda.

A natureza, quantidade, diversidade e nocividade das drogas apreendidas, o local dos fatos (conhecido ponto de traficância), e a forma de acondicionamento (frascos e invólucros plásticos que separam as porções destinadas à mercancia ilícita), aliados ao comportamento do agente, tudo está a indicar claramente destinarem-se os entorpecentes ao comércio ilícito.

Frise-se que a situação de pandemia facilita e favorece a prática do tráfico de drogas, uma vez que menos pessoas e policiamento estão nas ruas, em vista do isolamento social, propiciando que os traficantes e usuários se encontrem com mais frequência e tranquilidade, e que a droga seja transportada e armazenada de forma mais desvigiada, sendo claro que o indiciado se valeu de tal situação de exceção para melhor levar a cabo suas atividades ilícitas.

Posto isto, denuncio FERNANDO TUMIERO DE OLIVEIRA como incurso nos artigos 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, c.c. 61, II, "j", do Código Penal, e requeiro, uma vez notificado a ofertar defesa preliminar, seja recebida esta denúncia, citado e interrogado o agente, prosseguindo o feito em seus ulteriores termos, até final sentença condenatória, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, conforme artigos 54 a 59 da referida Lei de Tóxicos.

Em decisão de fls. 77-79 foi recebida a denúncia e determinada a citação do acusado.

Às fls. 81-83, o advogado do réu juntou procuração e requereu a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária.

Decisão de fl. 84 deferiu-lhe os benefícios e a decisão de fl. 85, designou audiência de instrução e julgamento.

Resposta à acusação foi feita em audiência, às fls. 102-103.

Não sendo o caso de absolvição sumária, em audiência de instrução e julgamento, redesignou-se o ato para oitiva da testemunha faltante (fls. 102-103).

Realizados os atos, foram: [a] colhidas provas testemunhais (audiência virtual); e [b] interrogado o réu.

Na fase do artigo 402, do CPP, as partes nada requereram.

Após realizaram debates orais (os quais foram gravados), passei à sentença.

2 A fundamentação

2.1 O mérito

2.1.1 O crime de tráfico

Na peça exordial, o Ministério Público do Estado de São Paulo imputa a prática do delito previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 do CP ao réu FERNANDO TUMIERO DE OLIVEIRA.

A materialidade e a autoria são comprovadas pelos seguintes elementos: [a] auto de exibição e apreensão (fls. 7-8); [b] laudo de constatação (fls. 11-14); [c] fotografia (fl. 14); [d] laudo pericial definitivo (fls. 91-93); e [e] audiência de instrução e julgamento.

Com efeito, tanto o laudo de constatação quanto o definitivo fizeram a indicação de que, nos objetos analisados, foi observada a presença de: [a] 73,3g (setenta e três gramas e três decigramas) de Tetrahydrocannabinol, mais conhecida como "maconha", em 46 (quarenta e seis) porções; e [b] 7,84g (sete gramas e oitenta e quatro decigramas) de "cocaína", em 10 (dez) invólucros plásticos.

Referidas substâncias são consideradas como droga, nos termos do previsto no parágrafo único do art. 1º da Lei n. 11.343/2006, o qual estabelece considerar-se como tal "as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União". A lista mencionada foi indicada nos laudos periciais logo após a identificação de cada uma das porções.

No que tange à caracterização do tráfico, vê-se que pela forma em que acondicionadas as substâncias (divididas em várias porções que estavam em plásticos, conforme fotografia de fl. 14), estavam separadas e preparadas para posterior venda. Ademais, o comportamento do agente ao tentar dispensar a sacola em que estavam os entorpecentes, corroboram para a caracterização da atividade de tráfico.

De outro turno, os depoimentos fazem concluir no mesmo sentido.

A testemunha Policial Militar Juliana Barbara Agostinho de Carvalho em seu depoimento narrou que não se recorda da ocorrência no local informado neste ato. Se recorda do réu, por outra ocorrência, mas não se recorda por esta.

A testemunha Thiago Maciel Tome disse que estavam em patrulhamento em local conhecido pelo tráfico, uma praça; o réu estava no meio da praça sentado; quando percebeu a presença da equipe, dispensou uma sacola plástica e foi caminhando; o abordaram, voltaram e pegaram a sacola e deram voz de prisão; havia maconha e cocaína dentro da sacola; primeiramente o réu falou que não era dele e, após, confessou que era dele; eram em torno de 40 (quarenta) ou 45 (quarenta e cinco) invólucros de maconha e mais uma quantidade de cocaína; não se recorda se anterior ou posterior, mas ele já foi preso por tráfico pela equipe do depoente; foi em local diferente, também conhecido pela prática de tráfico; havia somente ele no centro da praça, sentado; o réu saiu andando rápido; a sacola ficou próximo ao local em que ele estava sentado; fez prisão em outra ocasião, em que estava em uma residência onde já foram efetuadas diversas prisões, também confessando; e a prisão foi próxima à Rua Comendador Emilio Romi, e a outra foi em uma viela, em local diverso.

Interrogado, o réu Fernando Tumiero de Oliveira gizou que a acusação não é verdadeira; foi na praça comprar; era realmente um local de tráfico; a praça estava lotada, tinha gente jogando bola; perceberam a viatura e correram; o menino correu e jogou a sacola perto do interrogado; ele ficou; foi abordado em seguida, perguntando do menino; falou que não sabia de quem era; falaram que já que não queria dizer de quem era, iria preso; falaram que já tinham prendido uma vez; saiu junto, estava andando e foi abordado; estava andando porque não estava com nada; a outra vez foi pelo tráfico também; falou que não ia falar de quem era; a praça tinha bastante gente; não conhece essas pessoas; como não conhece ninguém, não tem ninguém para confirmar; sabia que era biqueira, mas não conhecia ninguém; tinha ido comprar maconha; estava com R\$ 20,00; continuava com o dinheiro quando os policiais fizeram a abordagem; e não sabe o porquê não está no auto de exibição e apreensão. Logo, do que se viu, a droga estava preparada para venda, dentro da bolsa que o réu dispensou ao avistar os policiais militares, em local já conhecido por se tratar de ponto de venda de drogas.

Ao assim agir, incidiu no disposto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, o qual classifica como crime "importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar", devendo incidir nas penas a ele cominadas.

Quanto às teses de defesa, a versão do acusado restou isolada no contexto dos autos. Com efeito, disse que teria ido ao local para comprar drogas, porém nenhum valor foi apreendido, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 7-8). Além disso, afirma que teria havido a fala dos policiais de que, como já havia sido preso outra vez, provavelmente estaria envolvido com o tráfico, todavia a prisão mencionada aconteceu após os fatos ora analisados. A par disso, o depoimento do policial foi no sentido de que não havia outras pessoas no local. O fato de ter saído caminhando, por si só, não permite concluir pela falta do crime, notadamente porque isso inclusive poderia ser utilizado como tática de eventuais agentes para postular futura absolvição.

Além disso, não há qualquer dúvida sobre a imputabilidade do réu em relação a tais fatos, o que sequer chegou a ser ventilado na hipótese.

2.2 A dosimetria da pena

No que tange à dosimetria da pena, em relação ao réu Fernando Tumiero de Oliveira,

destaco, na primeira fase (pena-base), que, de acordo com o art. 59 do CP: [a] a culpabilidade (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie; [b] não há maus antecedentes a serem considerados (fls. 97-98, o réu é primário); [c] inexistem informações suficientes acerca da conduta social (meio como se comporta no seio da sociedade) ou da personalidade (características pessoais advindas de sua psique); e [d] os motivos (as razões de sua prática), as circunstâncias (modo em que ocorreu) e as consequências (situações advindas da prática) também não se apresentam destoantes do que normalmente se espera nesses casos.

Saliento, por oportuno, que: [a] “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base” (Súmula n. 444 do STJ); e [b] “a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial” (Súmula n. 241 do STJ).

A natureza e a quantidade de drogas devem ser consideradas, pois apreendidos 73,3g (setenta e três gramas e três decigramas) de Tetrahydrocannabinol, mais conhecida como “maconha”, em 46 (quarenta e seis) porções e 7,84g (sete gramas e oitenta e quatro decigramas) de “cocaína”, em 10 (dez) invólucros plásticos.

Assim, majoro a pena em 1/6 (um sexto) e fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa para o crime de tráfico de drogas.

Destaco a inexistência de agravantes e a ocorrência da atenuante da menoridade relativa.

Não reconheço a agravante de crime praticado em caso de calamidade pública (em razão da pandemia de COVID-19), nos termos do art. 61, inciso II, 'j', do CP, porquanto referido estado não teve relação direta com a prática do crime (no mesmo sentido, desta Corte: TJSP; Apelação Criminal 1520980-88.2020.8.26.0228; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/04/2021; Data de Registro: 06/04/2021).

Saliento que: [a] “a incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (Súmula n. 231 do STJ), o que, por consequência, também inviabiliza sua majoração além do máximo; [b] nos termos do já destacado acima, “a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial” (Súmula n. 241 do STJ); e [c] “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal” (Súmula n. 545 do STJ).

Diante disso, devolvo a pena ao mínimo, notadamente pela impossibilidade de redução abaixo do mínimo legal nesta fase.

Na terceira fase (pena-definitiva), destaco a inexistência de causas de aumento de pena ou de diminuição. Quanto ao tráfico privilegiado, embora o réu seja tecnicamente primário e de bons antecedentes (fls. 97-98), foi condenado, com trânsito em julgado, por tráfico cometido meses após a liberação no presente feito, dando conta de que se dedica às atividades criminosas.

Quanto à detração (art. 387, § 2º, do CPP), entendo que é matéria afeta à execução penal (art. 66, III, 'c', da Lei de Execução Penal). Ademais, não alteraria o regime inicial na hipótese.

Estabeleço: [a] como regime inicial, o semiaberto, em razão do montante da pena e da inexistência de reincidência (art. 33, § 2º, 'c', do CP); e [b] o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos (art. 49, § 1º, do CP), notadamente por não haver outros elementos que possam indicar em sentido contrário.

No ponto, cabe destacar que: [a] “fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito” (Súmula n. 440 do STJ); [b] “a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula n. 719 do STF); e [c] “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou superior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais” (Súmula n. 269 do STJ).

Em razão do montante da pena, deixo de realizar a substituição por restritiva de direitos ou de determinar a sua suspensão condicional.

2.3 A indenização mínima

Deixo de fixar indenização mínima para a hipótese vertente, porquanto não houve pedido expresso nesse sentido na denúncia, o que impede sua concessão, conforme entendimento da Corte de Cidadania (AgRg no REsp 1673181/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018).

Ademais, mesmo que realizado o pedido em alegações finais, tal situação não é suficiente para fins de concessão, notadamente por inviabilizar o contraditório e a ampla defesa acerca do tema.

2.4 A prisão preventiva

O réu poderá apelar em liberdade com relação ao delito expresso nesta sentença, porquanto: [a] não apresentados indicativos da imprescindibilidade da segregação processual neste momento; e [b] respondeu ao processo em liberdade.

3 Dispositivo

Ante o exposto, com fulcro no art. 387 do Código de Processo Penal condeno o réu Fernando Tumiero de Oliveira pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, nos termos da fundamentação supra.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais. Contudo, a respectiva exigibilidade está suspensa, durante o prazo extintivo de 5 (cinco) anos, em face da presunção de hipossuficiência financeira, consoante arts. 3º do CPP e 98 a 102 do CPC.

O réu Fernando Tumiero de Oliveira poderá apelar em liberdade, conforme fundamentação acima.

Declaro o perdimento de eventual arma de fogo e de munição apreendida em favor da União (art. 91, II, alínea 'a', do CP), para os fins dos arts. 25 e 32, parágrafo único, do Estatuto do Desarmamento, se o caso.

Determino a perda de eventual fiança, cujo valor será vertido para pagamento das despesas processuais, nos termos do art. 336 do CPP, se o caso.

Determino a destruição de eventuais drogas ainda existentes, se o caso.

Fixo a remuneração do advogado dativo no máximo previsto na tabela da DPE/OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado: [a] comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do art. 15, III, da CF; [b] formem-se os autos de execução; e [c] proceda-se às demais determinações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpridas todas as determinações, arquivem-se.

São Paulo, 14 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA